



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א. שרייבר

תובע

דיסקין פיליפ,
באמצעות ב"כ: עו"ד שירה בירנבאום ואח'

נגד

נתבעים

1 לוי לורונט,
2 לוי נדל"ן בע"מ ח.פ. 513982355
באמצעות ב"כ: עו"ד אריה יעקב

פסק דין

ענייננו העיקרי של הליך זה הוא סעד להריסת אודיטוריום שבנו הנתבעים בקומה האחרונה של הבית המשותף ברחוב יואל משה סלומון 12 בירושלים, הידוע כגוש שומה 30049 חלקה 300 (להלן – הבית המשותף).

1. הבית המשותף הוא בניין לשימור, וכולל על פי מסמכי הרישום 17 יחידות משנה. לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם.
2. התובע הוא בעל יחידה בבית המשותף הרשומה כתת חלקה 1, ששטחה הרשום 46.2 מ"ר, ובבעלותו 5/98 חלקים ברכוש המשותף, והנתבעים הם בעלי היחידות הרשומות כתתי חלקות 2-17 ובבעלותם יתרת החלקים ברכוש המשותף.
3. הנתבע 1 הוא בעל המניות היחיד בנתבעת 2.
4. הבית המשותף מהווה חלק מפרויקט המכונה "כיכר המוזיקה", אותו מקדמים הנתבעים.
5. הנתבעים רכשו במהלך השנים את כל יחידות הבית המשותף למעט היחידה שבבעלות התובע. חלק מתתי החלקות רשומות בבעלות הנתבע 1 והיתר רשומות בבעלות הנתבעת 2.
6. יחידת התובע מהווה יחידה קטנה, ששטחה הרשום 46.2 מ"ר, בעלת כניסה נפרדת, בקומת המרתף של הבית המשותף, אשר הירידה אליה היא מקומת הקרקע, מסמטה צדדית, דרך מדרגות הצמודות ליחידה, וכן צמוד לה בצמידות משותפת עם תתי חלקות נוספות, חדר שירותים.

תמצית טענות התובע

7. לטענת התובע, הוא רכש את זכויות הבעלות ביחידה בשנת 1981. הבניין נרשם בפנקס הבתים המשותפים בשנת 2012. היחידה שבבעלות שימשה בעבר בחלק מהתקופות כבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מדרש. תקנון הבית המשותף אינו מצמיד את גג הבית למי מהיחידות ואינו קובע שניתן לבנות עליו. אחוזי הבניה של הבית המשותף שייכים לכל בעלי הדירות.

8. הנתבעים בנו קומה נוספת על גג הבית המשותף לצורך הקמת אודיטוריום, וזאת ללא היתר בניה כדין, שלא על בסיס תכנית מאושרת וללא הסכמת התובע, על אף זכויותיו כבעל דירה בבית המשותף. ככל שהייתה מוגשת בקשה להיתר כדין, הייתה ניתנת הזדמנות לתובע להתנגד לבניה. גם אם התובע נתן בעבר הסכמה לבניה אחרת על הגג, הרי שלכל המאוחר נודע לנתבעים על התנגדותו לבניה שהם מבצעים כעת כאשר הומצאה התנגדות לתב"ע במסגרתה תוכנן האודיטוריום. גם אם היה בעבר היתר בניה בידי הנתבעים לבנות על גג הבית המשותף, אין בכך כדי להעיד על הסכמה קניינית מצדו.

9. העבודות שביצעו הנתבעים גרמו לפגיעה ברכוש המשותף הן משום ששינו את חזונו החיצוני של הבית המשותף והן משום ששינו את אופיו שכן קיום אודיטוריום יביא לקהל גדול שיגיע לבית המשותף.

10. כמו כן, הבניה שבצעו הנתבעים מהווה תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, ואינה שימוש סביר ורגיל. לחזקה ייחודית כאמור, המהווה בפועל הצמדה של חלק מהרכוש המשותף, נדרשת הסכמה של 100% מבעלי הדירות, והסכמתם צריכה להיות מפורשת.

11. התובע מעולם לא נתן הסכמה לבניה האמורה.

12. הנתבעים לא הוכיחו שהוא נהנה מהבניה שביצעו או שהיא העלתה את ערך הדירה שלו. בנוסף, הנתבעים מעולם לא פנו אליו לבקש החזר כספי בגין עבודות ברכוש המשותף ולא זימנו אותו לאסיפה כללית בעניין, וככל שהתקיימה אסיפה כזו, הרי שהתקיימה שלא כדין.

13. העדה בניסטי מטעם הנתבעים העידה עדות שמיעה ואין לה ידיעה אישית על העובדות אודותיהן העידה.

תמצית טענות הנתבעים

14. לטענת הנתבעים, התובע נוקט בהליכים רבים חסרי בסיס, ומטרתו היא סחיטת הנתבעים, כדי שיקנו את היחידה המוזנחת שבבעלותו במחיר מופקע.

15. האודיטוריום נבנה כבר בשנת 2017 והתובע היה מודע לכך ואף בירך על כך.

16. התובע אינו מתגורר בישראל, ומגיע לארץ לעיתים רחוקות, ומעולם לא שילם דמי ועד בית ולא השתתף בתחזוקת הרכוש המשותף. התובע הסכים לשיפוץ הבית המשותף על פי חזונו של הנתבע 1. במקביל התובע הזניח את היחידה שבבעלותו באופן מכוער.

17. עד לשנת 2015 הבעלים הרשום של יחידת התובע הייתה רשות הפיתוח והיא הסכימה לפעולות שבוצעו בו. בשנת 2015 נרשם התובע כבעלים. הנתבעים ביצעו שיפוצים משמעותיים של הנכס והתובע לא התנגד להם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. האודיטורים נבנה בשנת 2017. הרשות לבנות על גג הבית המשותף נתנה לבעל זכויות בשם מזרחי אשר הנתבעים רכשו את זכויותיו ובאים בנעליו.

19. התובע הסכים לבניה בדברים שכתב ובהתנהלותו, ואף ביקש להיות שותף בעשייה התרבותית באודיטורים. התובע קיבל תמורה על הסכמתו בכך שלא נדרש להשתתף כלל בשיפוץ המשמעותי של הבית המשותף. התובע אינו רשאי לחזור בו מהסכמתו.

20. עדותו של התובע הייתה חמקנית וכללה סיפורים שאין להם בסיס במציאות.

21. גם אם תתקבל טענת התובע שמדובר ברכוש משותף שהסכים להשבחתו ולא ויתר עליו, הרי שמדובר ברכוש משותף מושבח לטובת כלל בעלי הדירות, והשימוש בו נתון להכרעת האסיפה הכללית. האודיטורים מושכר בשכירות חודשית בלתי מוגנת וצפוי להכניס כסף לקופה המשותפת.

ההליך

22. התביעה הוגשה ביום 31.1.2019 ונדונה תחילה בפני כב' המפקחת (כתוארה אז) י' ענתבי שרון אשר קיימה דיון מקדמי ביום 13.6.2019.

ביום 27.1.2020 אמורה הייתה להתקיים ישיבת הוכחות, אשר נדחתה באותו יום בשל בעיה רפואית דחופה של ב"כ הנתבעים.

לאחר מינויה של כב' המפקחת ענתבי שרון לשיפוט, הועבר ההליך לטיפול הח"מ.

ישיבת ההוכחות שהייתה קבועה בפני הח"מ נדחתה בשל מצבו הרפואי של התובע.

ביום 15.11.2021 התקיימה ישיבת הוכחות הנדחית בפני הח"מ במסגרתה נחקר התובע בלבד, תוך שב"כ הנתבעים ביקש לדחות את חקירת העדים מטעמו. לפיכך נקבעה ישיבת הוכחות נוספת לחקירת עדי ההגנה, אשר נדחתה בהסכמת הצדדים והתקיימה בסופו של דבר ביום 23.5.2022. מטעם הנתבעים נחקרו האדריכל מרואני, אדריכל הפרויקט, והגב' דבורה בניסטי, מנהלת משרד הנתבעת 2.

ביום 14.6.2022 התקיים ביקור במקום לאחריו הוגשו סיכומי הצדדים בכתב.

דיון והכרעה

23. הסעדים שביקש התובע הם להורות לנתבעים להרוס את כל תוספות הבניה הלא חוקיות שנבנו על הרכוש המשותף בניגוד לדין, לרבות תוספת הקומה החדשה ולהשיב את המצב לקדמותו, וכן מתן צו שיאסור עליהם בניה עתידית ברכוש המשותף ללא קבלת היתר בניה וללא קבלת הסכמת יתר בעלי הדירות כדון, ולמניעת נקיטה בהליכי רישוי הגורעים מזכויות התובע ללא הסכמתו.

טענות וסעדים בהיבטים תכנוניים

24. למעט נושא האודיטורים, שידון בהמשך בהיבטיו הקנייניים, התובע לא פירט בכתב התביעה או בתצהיר שהגיש מהן התוספות האחרות שנבנו לטענתו באופן לא חוקי או ללא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היתר, וטען טענות כלליות בלבד בהקשרים אלו. על כן, התובע לא הוכיח את טענותיו בעניין.

25. יתר על כן, ערכאה זו אינה עוסקת בהיבטים תכנוניים, מלבד הצורך לבחון בהקשרים נקודתיים קיומם של תנאים תכנוניים בשל הוראות החוק הקנייני. כך לדוגמה באשר להליך העוסק בהרחבת דירה, מוגדרת הרחבה על פי סעיף 71א לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 להגדלה של שטח דירה שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף, וכן בנוגע לאישור עבודות חיזוק, בשל הוראת סעיף 2(א) לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 הקובע כתנאי סף לתחולת הוראות החוק קיומו של היתר לביצוע עבודות חיזוק (או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים). מלבד אותם הקשרים נקודתיים, הרי שטענות באשר לביצוע עבודות שלא בהתאם למצב התכנוני יש להפנות לרשויות התכנון ולערכאות האמונות על נושאים אלו.

26. יפים לעניין זה הדברים שכתב חברי, כב' המפקח מאיר פורת בתיק (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא (נבו 14.03.2022):

"כידוע, ישנה הפרדה בין ההליך התכנוני לבין ההליך הקנייני. לפיכך נפסק כי ככלל, סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, ואין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות (עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ, בפסקה יב (נבו 09.01.2011) בג"ץ 1578/90 הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א (נבו 24.10.1990)). המפקח על רישום מקרקעין, אינו דן בנושאים תכנוניים, אלא בנושאים קנייניים בהתאם לסמכותו לפי חוק המקרקעין. לפיכך, אין הוא צריך להידרש לטענות הקשורות להיבטים תכנוניים. טענות אלו צריכות להתברר במוסדות התכנון. אלא לעיתים, על המפקח להידרש גם לנושאים תכנוניים, ולבדוק האם בידי הצד הרלבנטי להליך, היתר כדון מטעם הרשות התכנונית... כאשר מתבררת טענה כי בעל דירה ביצע שינויים ברכוש המשותף שעניינם "הרחבת דירה" על המפקח לבחון, בין היתר, האם אותה "הרחבה", היא כזו "שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף" (ראו הגדרת המושג הרחבה בסעיף 71א לחוק המקרקעין)... יודגש - המפקח על רישום מקרקעין אינו משמש מוסד תכנוני, הוא אינו יושב כערכאת ערעור על הנושאים התכנוניים, וממילא אין בסמכותו לאכוף היבטים תכנוניים. אך כאמור לעיתים עליו לבחון האם בידי הצד שבפניו, היתר תכנוני שהוא תנאי לבחינת ההיבט הקנייני."

27. לפיכך, הסעדים המבוקשים על ידי התובע בהיבטי תכנון ובניה, לעניין הריסת תוספות בשל הטענה שנבנו ללא היתר בניה או מניעת בנייה עתידית ללא היתר בניה או מניעת נקיטה בהליכי רישוי, נדחים.

טענות לעניין אי עמידה בדרישות קנייניות ביחס לתוספות הבניה

28. התובע לא פירט בכתב התביעה או בתצהיר שנתן את התוספות שנוספו לטענתו ושאותן הוא מבקש להרוס, והאופן בו הם פוגעים לטענתו ברכוש המשותף. הן כתב התביעה והן התצהיר מטעמו של התובע כוללים אמירות כלליות בהקשר זה. כך לדוגמה בסעיף 34



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתצהירו טוען התובע ש"חלקים נרחבים מהבניה שבוצעה על ידי הנתבע בוצעה ברכוש המשותף" תוך הפניה לתשריט הבית המשותף, ללא פירוט של מהי הבניה שבוצעה ברכוש המשותף, ואלו חלקים ממנה אינם תואמים את תשריט הבית המשותף, ומה בקשתו לעניין אותם חלקים. העניין היחיד אליו התייחס התובע באופן פרטני הוא נושא פירוק גג הרעפים בגג הבית המשותף ובניית קומה נוספת, שלישית, אשר אמורה לשמש כאודיטוריום (להלן – האודיטוריום). עניין זה יידון בהמשך.

29. לאור האופן בו פורטו טענות התובע, ולאור חומר הראיות שהוגש לתיק, טענות התובע בכל העניינים הנוגעים לשינויים ברכוש המשותף שאינם בנוגע לאודיטוריום, נדחות, כפי שאנמק להלן.

30. ראשית, מדובר כאמור בטענות כלליות הן באשר לשינויים שבוצעו והן באשר לפגיעה הנטענת ברכוש המשותף. התובע לא הציג כלל ראיות לטענותיו מלבד טענות כלליות שטען בתצהירו. בסעיף 29 לתצהירו טען התובע שבמסגרת הבקשה להיתר ביקשו הנתבעים לאשר תוספות של שירותי גברים ונשים, מחסן, מעלית, מדרגות ועוד. בסעיף 32 לתצהירו טען שלמרות שההיתר לא ניתן העבודות בוצעו בשטח. מעבר לטענות אלו, לא ניתן כל פירוט המבהיר מה מתוך העבודות האמורות בוצע ברכוש המשותף, היכן בוצעו ברכוש המשותף (לצורך השבת המצב לקדמותו) ומהי הפגיעה שנגרמה בעקבות כך לרכוש המשותף. לפיכך התובע לא הוכיח כל פגיעה שנגרמה לרכוש המשותף כתוצאה מהשינויים שביצעו הנתבעים.

31. שנית, לא רק שהתובע לא הוכיח שנגרמה פגיעה כלשהי לרכוש המשותף, מטענות הנתבעים עולה שהם השביחו את הרכוש המשותף על חשבונם, וטענות אלו לא הופרכו על ידי התובע.

מראיות הנתבעים עולה שהבניין היה מוזנח ביותר טרם השיפוץ, ואף התקבלה בעבר התראה מהמחלקה למבנים מסוכנים בעיריית ירושלים על הצורך בחיזוק המבנה (סעיף ו' לתצהיר מרואני מטעם הנתבעת). כן עולה כי הנתבעים השקיעו כספים רבים בשיפוץ הבית המשותף, כעולה מתצהירה של הגב' בניסטי מטעם הנתבעים לעניין תיקון הקירות החיצוניים, יסודות הבניין, חדרי השירותים המשותפים וכו' (ר' סעיפים ב' ג' לתצהירה, וכן תמונות שצורפו לתצהיר בנוגע למצב הבית המשותף טרם השיפוץ בו נראה הבית מוזנח ביותר).

בנוסף, מתצהיר מרואני, אדריכל הנתבעים, עולה כי הנתבעים ביצעו עבודות בהיקף נרחב תוך תיאום עם מחלקת שימור מבנים בעירייה, כדי לשקם את הבניין שהיה הרוס לחלוטין (ר' סעיפים ו' ז' לתצהירו). בנוסף, הנתבעים העבירו חלק מהשטחים הפרטיים לטובת הרכוש המשותף (ר' סעיף ח' לתצהירו). מכאן שמטרת ביצוע העבודות על ידי הנתבעים ברכוש המשותף הייתה לשקם את הבניין ממצב של סטנדרט ישן ומוזנח ואף מסוכן, למצב חדש ומשופץ תוך שמירה על אופיו בהתאם להנחיות מחלקת שימור מבנים בעירייה. עדותו של מרואני לא נסתרה, ותומכת בטענת הנתבעים שהרכוש המשותף הושבח ולא נפגע כתוצאה מהעבודות שביצעו.

בביקורי במקום התרשמתי כי בניגוד ליחידה הקטנה של התובע, שנתרה מוזנחת, יתר הבית המשותף עבר שיפוץ משמעותי שכלל לובי מרשים, תוספת מעלית, מעבר פתוח לציבור ועוד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. שלישית, התובע, אף שהיה מודע לשינויים המשמעותיים הנערכים בבית המשותף, לא התנגד לשינויים אף שהיה בקשר עם הנתבע 1, והביע את מורת רוחו רק בעניינים שוליים וספציפיים הנוגעים ליחידה שבבעלותו, לדוגמה כאשר נחסמה דלת חירום שהובילה ליחידה זו, דבר שנוהל במסגרת הליך נפרד (ר' לדוגמה חקירתו הנגדית של התובע בפרוטוקול הדיון מיום 15.11.2021 עמוד 2 שורות 30-34 שם אומר התובע בין היתר, בהתייחס לשיחות עם הנתבע 1 בשלבים שקדמו לתביעה קודמת, שהנתבע 1 אמר לו שהוא צריך את היחידה שלו התובע לצורך מעבר ויציאה מהמוזאון). אגב אותו העניין, התובע אף הביע את תמיכתו בחזון של הנתבע 1 בנוגע למוזיקה (כאשר מהקשר הדברים עולה שכוונה למוזיאון ולכיכר המוזיקה), ככזה המצדיק "נובל", כלשונו (ר' דוא"ל מיום 22.10.2015 שצורף לתצהיר בניסטי).

התובע פירט בתצהירו אודות אותו הליך אחר שנקט בעבר כלפי הנתבעים, שתחילתו בשנת 2016, בגין טענה שהנתבעים סגרו דלת חירום בלובי הבית המשותף המובילה ליחידה שלו, ומספר עניינים נוספים בנוגע לשינויים ברכוש המשותף. כעולה מתצהירו של התובע, אמנם התקיים הליך משפטי באותו עניין והנתבעים חויבו במסגרת פסק דין להסיר את קיר האבנים שבנו תוך חסימת אותו פתח. לטענת התובע, הנתבעים לא מילאו באופן מלא אחר פסק הדין והתובע הגיש בקשה לביזיון בית משפט בעניין (סעיפים 23-26 לתצהירו).

בנוגע לאותה דלת, ולשינויים נוספים שפורטו באותו הליך, וככל שהתובע ביקש לכלול עניינים אלו בסעדים הכללים להם עתר, הרי שמדובר במעשה בית דין ועל כן אין מקום לדון בנושא זה בענייננו.

עם זאת, עצם העובדה שהתובע כבר ניהל הליך בטענה לפגיעה בזכויותיו עקב העבודות שביצעו הנתבעים, בשלב שבו העבודות היו בעיצומן, ומצא לנכון להתייחס במסגרתו רק למספר מצומצם של עניינים ובעיקר לדלת החירום, תוך ששיבח את הנתבע 1 על החזון שלו שבא לידי ביטוי בפרויקט שבוצע בבית המשותף, מעלה תהיות לעניין טענותיו הנוכחיות הכלליות באשר לפגיעה שנגרמה לו לטענתו בשל כלל העבודות. יתר על כן, על פי תקנות 44, 45 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 שחלו בעת שהוגש ההליך האחר, היה על התובע לכלול בתביעתו את כל הסעדים בגין עילת התביעה באותו הליך, ואף שעיקר הבניה ברכוש המשותף כבר הייתה קיימת בעת שהוגשה התביעה נשוא אותו הליך, לא נכללו בה הסעדים נשוא הליך זה, דבר המעלה ספק לעניין זכותו להעלותם בהליך הנוכחי.

תוך כדי אותו הליך, אשר הסתיים בפסק דין ביום 1.1.2019 (ר' נספח 5 לתצהיר התובע) המשיך התובע להיות בקשר עם הנתבעים בין היתר באמצעות כתיבת הודעות דוא"ל, תוך שהציע שיתוף פעולה לגבי הפרויקט המבוצע והביע את רצונו להיות שותף לו (ר' לדוגמה הודעות דוא"ל מספר 9 ו-10 משנת 2018 שצורפו לתצהיר בניסטי מטעם הנתבעים).

בנסיבות אלו, אף אם לא נתנה הסכמה מפורשת של התובע לשינויים שבוצעו בבית המשותף, הרי שהתנהלותו מלמדת שהיה מודע לעבודות לפחות מאז שנת 2013 (כפי שאף עולה מחקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 15.11.2021 עמוד 6 שורות 43-38), לא התנגד להן, למעט לעניין דלת החירום ומספר עניינים נוספים בעניינם נקט בהליך משפטי. לאור האמור, דרישה מאוחרת כעת להשבת המצב לקדמותו, לאחר שהנתבעים השקיעו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משאבים רבים בשיפוץ הרכוש המשותף ושינו מצבם לרעה מנוגדת לחובת תום הלב ואינה יכולה להקנות זכות לתובע לקבל את הסעד המבוקש.

33. די באמור לעיל כדי לדחות את טענות התובע בעניינים אלו. אולם גם אם הייתה מתקבלת טענת התובע לפגיעה כלשהי ברכוש המשותף בשל השינויים שבוצעו על ידי הנתבעים, הרי שזכותם של הנתבעים, כבעלי רוב הזכויות בבית המשותף, להחליט על שינויים בבית המשותף כל עוד אלו אינם פוגעים בזכויותיו של התובע. מלבד טענות התובע לעניין האודיטוריום, התובע לא פירט כל פגיעה שנגרמה לו לטענתו בגין השינויים ברכוש המשותף, וכן לא נדרש לשלם עבור השינויים שבוצעו. לפיכך התובע לא הוכיח שהשינויים האמורים בוצעו ללא הסכמות כדון, או שפגעו באופן כלשהו בזכויותיו, כפי שיפורט להלן.

סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת **לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969** (להלן – חוק המקרקעין), החל על הבית המשותף על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם, קובע שהאסיפה הכללית היא שקובעת את דרכי ניהולו של הרכוש המשותף.

סעיף 2(א) לתקנון המצוי, החל אף הוא, קובע שהאסיפה הכללית רשאית לאשר שינויים ברכוש המשותף כתוצאה משינויים שמבצע בעל דירה בדירתו, **אף כאלו הפוגעים ברכוש המשותף**, לרבות בחזות החיצונית התקינה והאחידה שלו.

סעיף 12 לתקנון המצוי, שאף הוא חל על הבית המשותף דנן, קובע שהחלטות האסיפה כללית יתקבלו ברוב דעות, אולם לא תתקבל החלטה המטילה על בעל דירה תשלומים שלא פורשו בחוק או בתקנון, או משנה את זכויותיו, אלא אם בעל הדירה הסכים לה.

הפסיקה אף קבעה שאין להחיל על ניהול האסיפות ואופן קבלת ההחלטות במסגרתן, מנגנונים משפטיים סבוכים ופורמאליים, אשר אינם תואמים את אופי התנהלותם, וכי ניתן לראות בביצוע תשלום בדיעבד על ידי בעלי דירות כאשרור בדיעבד של החלטה לבצע תיקונים ברכוש המשותף אף אם אותם בעלי דירות לא נכחו באסיפה הכללית שהחליטה על כך [ר' עש"א (מחוזי ת"א) 35916-07-21 **אהרן לידסקי נ' נציגות הבית המשותף מרח' וילסון 4 תל אביב**, בפסקה 16 (נבו 6.2.2022)]. במקרים כאמור, ככל שמדובר בעבודות שתכליתן תחזוקה שוטפת של הבית המשותף, ואף שיפוצו באופן המביא אותו לסטנדרט חדש התואם את תנאי הזמן והמקום, לא רק שניתן לבצע את אותן עבודות, אלא שניתן אף לחייב בעל דירה שהתנגד להן, לשאת בחלקו בעלות העבודות.

בענייננו, הנתבעים הם בעלי רוב הדירות בבית המשותף ויש להם רוב של כ-95% ברכוש המשותף. במצב דברים זה, גם אם לא התקבלה החלטה פורמלית של האסיפה הכללית, מובן שקיימת הסכמה של רוב בעלי הזכויות באסיפה הכללית לבצע את השינויים שבוצעו ברכוש המשותף, כנדרש בסעיף 12 לתקנון המצוי. אמנם ניתן לראות פגם בכך שהנתבעים לא זימנו את התובע לאסיפה כללית שתדון בשינויים האמורים טרם בוצעו, אך פגם כאמור אינו שולל את זכותם של הנתבעים להחליט על כך, במיוחד כאשר תוצאות ההחלטה משביחות את הרכוש המשותף, מבלי לתפוס חזקה ייחודית בו, תוך שהתובע כלל אינו נדרש להשתתף בהוצאות הכרוכות בכך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהקשר זה יש להוסיף, שאף שלא התקיימה אסיפה כללית טרם ביצוע השינויים, הרי שהגורמים הרלוונטיים, דהיינו התובע והנתבעים שנציגם הוא הנתבע 1, נפגשו זה עם זה ודיברו על השינויים כמפורט לעיל, והתובע היה מודע לכוונת הנתבע 1 לבנות בבית המשותף את מוזיאון המוזיקה לפחות מאז שנת 2013 (ר' לדוגמה חקירתו הנגדית של התובע בפרוטוקול הדיון מיום 15.11.2021 עמוד 2 שורות 34-30).

מדברים אלו עולה שגם אם היה מקום לכינוס אסיפה כללית טרם ביצוע העבודות, מדובר באסיפה כללית שאמורה הייתה לכלול את התובע והנתבע 1 בלבד, אשר ממילא ניהלו שיח ביניהם שנגע לרצונו של הנתבע 1 לרכוש את יחידת התובע לצורך ביצוע העבודות, ועל כן מדובר בעניין פורמלי בעיקרו. כמו כן, התובע היה מודע לעבודות המבוצעות בזמן אמת, ולמעט עניין דלת החירום ומספר קטן של עניינים נוספים בגינם הגיש תביעה בהליך אחר, לא התנגד להם, כפי שפורט לעיל.

מכאן שלנתבעים הייתה זכות כרוב גדול של בעלי זכויות בבית המשותף, לקבל החלטות בדבר שינויים משביחים ברכוש המשותף, וענין כינוס אסיפה כללית, שמשמעותו פגישה בין התובע לנתבע 1, הוא עניין פורמלי בעיקרו, שגם אם לא התקיים, אין בו כדי להביא למסקנה שקיימת זכות לתובע כיום להביא להשבת המצב לקדמותו, אף אם היה מוכיח פגיעה ברכוש המשותף כתוצאה מהשינויים שבוצעו.

34. לאור האמור, הסעדים המבוקשים בנוגע לרכוש משותף שאינו קשור באודיטוריום נדחים.

האם קיימת הסכמה של התובע לבניית האודיטוריום?

35. התובע טוען שמעולם לא הסכים לבניית האודיטוריום. הנתבעים טוענים שהתובע הסכים לבניית האודיטוריום ואף תמך בה. לטענתם, האודיטוריום היה בנוי כבר בשנת 2017. עוד לטענתם, התובע הגיש תביעה בנוגע לחסימת דלת החירום של הנכס שלו בשנת 2018, לאחר שהאודיטוריום היה בנוי, ולא עתר לכל סעד בעניין. בנוסף לטענתם, אמירות התובע בפרוטוקול הדיון באותו הליך וכן תכתובות הדוא"ל ששלח לאחר שהאודיטוריום היה בנוי, מעידים על כך שהסכים לבנייה. בנוסף לטענתם, התובע לא התנגד בעבר לבנייה על הגג שבוצעה מטעם בעל נכס אחר בבית המשותף, אשר האודיטוריום למעשה מחליף אותה ומוסיף עליה.

36. באשר לטענה שהתובע הגיש את התביעה בהליך אחר לאחר שהאודיטוריום היה בנוי – הרי שהדבר אינו מתיישב עם העולה מפסק הדין נספח 5 לתצהיר התובע, על פיו ההליך האחר התנהל כבר משנת 2016, בעוד שלטענת הנתבעים האודיטוריום היה בנוי רק בשנת 2017.

37. באשר לזכות הנתבעים לבנות על גג הבית המשותף, אני סבורה שבנסיבות דנן, זכות כאמור קיימת ובלבד שמדובר בבניה שתהווה חלק מהרכוש המשותף, ללא תפיסת חזקה ייחודית על ידי מי מבעלי הדירות, ושעל התובע, בנסיבות העניין, לא תוטל כל חבות כספית הנוגעת לתוספת בניה זו, כמפורט להלן.

38. על פי מסמכי הרישום, גג הבית המשותף מהווה רכוש משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. הנתבעים אינם מתייחסים בסיכומיהם בצורה מפורשת לשאלה האם כוונתם לכך שהתובע הסכים לבניית האודיטוריום בהיותו חלק מהרכוש המשותף של הבית המשותף, או שהסכים לכך שהנתבעים יבנו אודיטוריום לשימושם הבלעדי. מדובר בעניין מהותי, שכן הסכמה לבניית אודיטוריום לשימוש הנתבעים בלבד משמעותה שהתובע הסכים לוותר על חלק מהרכוש המשותף ששייך גם לו, ולייחדו לנתבעים, בעוד שבניית אודיטוריום המהווה רכוש משותף ללא חיוב התובע בעלויות הכרוכות בכך, לא בהכרח פוגעת בתובע, והדבר משליך גם על עניין ההסכמה הנדרשת לכך. לשם הוכחת הסכמה לוותר על חלק מהרכוש המשותף, נדרשים תנאים מחמירים יותר מאשר להסכמה לשינויים ברכוש המשותף.

40. בשונה מחוסר הבהירות שבסיכומי הנתבעים, מתצהירה של הגב' בניסטי מטעם הנתבעים נטען עובדתית בעמוד 5 סעיף 2, שהגג והאודיטוריום שעליו **נשאר רכוש משותף**, ובהקשר לכך נטען שכונסה ישיבה של בעלי הדירות לאחר הגשת התביעה, והתובע הוזמן ולא הגיע אליה, ובמסגרת הישיבה הוחלט על ניהול הרכוש המשותף, פתיחת חשבון בנק לוועד בית וכו' (סעיף 3 בעמוד 5 לתצהיר בניסטי). בסיכומיהם הוצגה הטענה כחלופית, למקרה שבו ייטען שהנתבע לא ויתר על חלקו ברכוש המשותף.

מכיוון שעולה מהתצהיר מטעם הנתבעים שהם עצמם ראו באודיטוריום רכוש משותף וכך גם התייחסו אליו לאחר הגשת התביעה במסגרת ישיבה אליה זומן לטענתם התובע, הרי שאין בסיס לטענתם לעניין הסכמה של התובע לחזקה ייחודית שלהם בגב הבית המשותף ובאודיטוריום. אם הנתבעים עצמם סברו, אף במועדים מאוחרים להגשת התביעה, שמדובר ברכוש משותף שבו יש זכות לתובע, הם מושתקים מלטעון טענה עובדתית מנוגדת בדבר זכות לחזקה ייחודית בשל הסכמה של התובע.

41. יתרה מכך, על פי סעיף 62(א) **לחוק המקרקעין**, הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית דורשת הסכמה של כל בעלי הדירות. על פי הפסיקה, הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם כאמור לבעל דירה דורשת הסכמה **מפורשת** ולא ניתן להסתפק בהסכמה משתמעת [ר' ע"א 5043/96 **גלמן נ' הררי-רפול**, פ"ד נ"ד(3) 389, 394(2000)]. הנתבעים, אשר מתייחסים בעצמם בתצהיר מטעמם לאודיטוריום כרכוש משותף, לא הציגו בראיותיהם כל הסכמה מפורשת של הנתבע לתת להם את זכויותיו ברכוש המשותף לצורך בניית האודיטוריום באופן שיהווה רכוש פרטי שלהם. גם תכתובת הדוא"ל מטעם התובע שהציגו הנתבעים כנספחים לתצהירה של הגב' בניסטי, כדי לחזק את טענתם בדבר הסכמת התובע לבניית האודיטוריום, מראים לכל היותר על רצונו של התובע להיות שותף בפרויקט או "בחזון התרבותי", ולא על נכונותו לוותר על זכויות בו, ככל שקיימות לו. מכאן, שהנתבעים לא הוכיחו שהתובע הסכים לבניית האודיטוריום כרכוש פרטי של התובעים.

42. גם היעדר התנגדות מצד התובע לבקשה להיתר בניה שהגיש בעל נכס קודם לבניה על גב הבית המשותף אינה יכולה להיחשב כהסכמה מפורשת לבניה, מה גם שהנתבעים מודים שבנו והרחיבו מעבר למה שהתבקש באותה בקשה (ר' חקירתה הנגדית של הגב' בניסטי מטעם הנתבעים בפרוטוקול הדיון מיום 23.5.2022 עמוד 7 שורות 30-49, סעיף יא לתצהיר מרואני מטעם הנתבעים וחקירתו הנגדית בעמוד 3 שורות 26-37). כמו כן, הנתבעים לא הוכיחו שהתובע ידע על הכוונה לבצע בניה כאמור, והטענה שרשות הפיתוח, שהייתה הבעלים הרשום של הנכס באותה עת הסכימה לבניה, לא נתמכה בכל ראיה שהיא, ולכן גם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אם ניתן היה להסתפק בהסכמת רשות הפיתוח כטענת הנתבעים (דבר המוטל בספק), לא הוצגה כל ראיה המוכיחה הסכמה מפורשת כנדרש.

43. המסקנה מהאמור היא שהתובע לא ויתר על זכותו הקניינית בגג המשותף.

44. לפיכך יש לבחון את החלופה על פיה הנתבעים בנו את האודיטוריום כרכוש משותף של הבית המשותף, אשר גם לנתבע יש זכויות בו.

האם מתקיימים התנאים לבניית האודיטוריום כרכוש משותף?

45. כאמור, על פי סעיף 5(א) לתקנון המצוי שבתוספת **לחוק המקרקעין**, בסמכות האסיפה הכללית להחליט על **דרכי ניהולו** של הרכוש המשותף והשימוש בו, ולפי סעיף 2(א) באפשרותה לאשר אף שינויים שעושה בעל דירה בדירתו **הפוגעים** ברכוש המשותף. המגבלה לעניין החלטות האסיפה הכללית היא זו המופיעה בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי לעניין היעדר תוקף של החלטות המשנות זכויות בעל דירה או לחייבו בתשלומים שאינו מחויב בהם על פי החוק או התקנון, ללא הסכמתו. משילוב הסעיפים האמורים לעיל עולה כי זכותה של האסיפה הכללית להחליט על שינויים ברכוש המשותף, ובלבד שאין בכך כדי לשנות מזכויות בעל דירה המתנגד לכך או להטיל עליו תשלומים שלא הסכים להם, ובמקרה של שינויים שעושה בעל דירה בדירתו, האסיפה הכללית רשאית לאשר שינויים כאמור אף אם הם פוגעים ברכוש המשותף.

בנוסף, הפסיקה אינה מחילה כללים נוקשים ופורמליים על החלטות אסיפה כללית, כפי שהוזכר לעיל.

במקרה דנן, וכפי שפורט לעיל, לאור ההיקף המשמעותי של זכויות הנתבעים ברכוש המשותף, גם אם לא התקיימה אסיפה פורמלית כדין, אין די בהתנגדות התובע כדי להביא למסקנה שהנתבעים לא היו רשאים לבצע את הבניה האמורה במסגרת הרכוש המשותף, כל עוד יוכח שאין בכך כדי לשנות זכויות התובע או לחייבו בתשלומים שאינו חייב בהם, ללא הסכמתו.

46. עם זאת, במקרה דנן, מדובר בשינויים מהותיים, שכן מדובר בבנייה של קומה נוספת שלימה על גג הבית המשותף הכוללת אודיטוריום עם מאות מקומות ישיבה (325 כנטען בסעיף 33 לתצהיר התובע). לפיכך יש מקום לבחון את החלטת הנתבעים כבעלי רוב בעלי הזכויות בבית המשותף, גם לאור האפשרות שהחלטותיהם פוגעות בתובע כמיעוט, וזאת בהיבטים נוספים על אלו המפורטים בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי.

47. לעניין סמכות אסיפה כללית להחליט בדבר השימוש ברכוש המשותף, נקבע כי על אף שהסעיף הרלוונטי הנוגע לשיתוף במקרקעין אינו חל על בתים משותפים, עדיין חלים עקרונות כלליים מכח הדין הכללי, כפי שנקבע לדוגמה בע"א (מחוזי ת"א) 991/97 **נציגות הבית המשותף נ. לילי אבן** (נבו 13.1.98):

"סמכותה של האסיפה הכללית לקבוע את השימוש ברכוש המשותף היא מוגבלת, ובעיקר על ידי עקרונות כלליים הקבועים בדין (ראו גם י. ויסמן, **דיני קניין**, חלק שני בעלות ושיתוף, ירושלים, תשנ"ז 1997, בעמ' 457). בדיני השיתוף הכלליים ישנה הגנה על השותף מפני קיפוח הרוב בענייני ניהול ושימוש ברכוש המשותף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(סעיף 30(ב) [לחוק המקרקעין](#)); הוראה זו נמצאת בפרק ה' לחוק ולכן אינה חלה בבתי משפט (ראו סעיף 56(א) לחוק). אך אין בדבר לפגוע בעקרונות הכלליים החלים בעניינינו מכוח הדין הכללי. האיסור על הגבלת השימוש הסביר והרגיל, בלא קביעת כל שימוש אחר ובלא הנמקה ממשית (כגון, שהדבר מהווה פגיעה ברכוש המשותף) מושתת על האיסור על שימוש לרעה בזכות החל בדיני המקרקעין בישראל מכוח סעיף 14 [לחוק המקרקעין](#). איסור זה מעוגן אף בעקרון תום הלב החל בהפעלת זכויות במקרקעין (על פי סעיף 39 ו-61(ב) [לחוק החוזים](#) (חלק כללי), תשל"ג (1973), ומוצא חיזוק גם בסעיף 3 [לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו](#), המגן על קניינו של האדם. בענין זה יש לציין, כי בלא אפשרות לשימוש סביר בקניינו של האדם, תושם לפלסטר זכותו בקנין. "

מכאן שהחלטת רוב בעלי דירות המקפחת את המיעוט, יכולה להיחשב כשימוש לרעה בזכות המנוגדת לסעיף 14 לחוק המקרקעין.

48. לאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות נשוא הליך זה, שוכנעתי שהחלטת הנתבעים לבנות את האודיטוריום אינה פוגעת בתובע כמפורט להלן.

49. ראשית, כאמור לתובע כ-5% בלבד מהזכויות ברכוש המשותף, ועל כן זהו שיעור זכויותיו גם בגג המהווה רכוש משותף. מיקומה של היחידה שבבעלותו הוא במרתף, באופן שלא הייתה לתובע כל אפשרות מעשית להשתמש בגג. כמו כן, בניית האודיטוריום תיצור גג משותף חדש לבית המשותף. התובע לא הצביע על כל פגיעה הנגרמת לו כתוצאה מהיעדר האפשרות להשתמש בגג המשותף במצב שקדם לבניית האודיטוריום, ונראה כי מעולם לא עשה כל שימוש בגג האמור. כמו כן התובע לא הוכיח פגיעה כלשהי הנגרמת מבניית האודיטוריום בבית המשותף, וטענותיו התמקדו בפגיעה ביחידה שבבעלותו. האודיטוריום, אשר לטענת הנתבעים יושכר, באופן שדמי השכירות יועברו לטובת הרכוש המשותף, מהווה נכס מניב עבור הבית המשותף. מכאן שהתובע לא הוכיח שבניית האודיטוריום כרכוש משותף פוגעת באופן כלשהו בזכויותיו ברכוש המשותף.

50. שנית, יש מקום להתייחס בהקשר זה גם להתנהלותו של התובע במועדים הרלוונטיים לבניית האודיטוריום, ולראיות שהציג בעניין. כעולה מהאמור להלן, גם אם הובעה באופן מסוים התנגדות מטעם התובע לאודיטוריום, התובע לא הוכיח התנגדות מפורשת הכוללת טעמים ענייניים.

התובע הפנה לאמירה כללית במכתב לקוני מיום 28.4.2015 מטעם ב"כ התובע לעניין התנגדותו לשינויים ברכוש המשותף ו/או במזגן המשרת את הנכס שלו, ולעניין הפתח לנכס מלובי הבניין, פנייה שנעשתה בין היתר בעקבות פניית הנתבעים אליו להסרת מזגן שהציב באופן הפוגע בחזות החיצונית של הבית המשותף (ר' נספח ח' לתצהיר בניסטי מטעם הנתבעים, וחקירתה הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 23.5.2022 עמוד 10 שורות 42-30). אם היו לתובע טענות באותו שלב בעניין בניית האודיטוריום, סביר שלא היה מעלה אותן באופן כללי תוך התמקדות בדרישתו שלא להזיז את המזגן המשרת את היחידה שלו. בהמשך כאמור התובע הגיש תביעה בהיבטים הנוגעים לסגירת הפתח ליחידה שלו ולמספר עניינים מצומצם בלבד, שעה שבוצעו עבודות משמעותיות בכל הבית המשותף. מכאן שהתובע עצמו הבהיר בהתנהלותו שאינו מתנגד באופן כללי לכל שינוי שהוא ברכוש המשותף, אלא רק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לכאלו הנוגעים ליחידה שבבעלותו. מעבר לכך לא הציג התובע פניות נוספות ששלח לנתבעים בהתייחס לאודיטוריום.

התובע לא סתר את הטענה שהאודיטוריום נבנה כבר בשנת 2017. לאחר מכן, ובמשך תקופה ארוכה, פנה התובע בשנת 2018, לאחר שהאודיטוריום כבר היה בנוי, כ-10 פעמים לנתבע 1 בדוא"ל בעניינים שונים ובכללם הצעה שהנתבע 1 ירכוש את זכויות התובע ביחידה, הצעה לשיתוף פעולה בנוגע לחזון, טענות בנוגע לסגירת הפתח ליחידה ועוד, ולא הזכיר בכל דרך התנגדות לבניית האודיטוריום ולא טען להפרעה כלשהי בשל קיומו (ר' מסמכי דוא"ל שצורפו כנספחים לתצהיר בניסטי מטעם הנתבעים, אשר התובע לא הכחיש ששלח אותם). מהודעות הדוא"ל ששלח התובע עולה כי ביקר בישראל במהלך שנת 2018, לכל הפחות בשל ההליך שניהל בנוגע לסגירת הפתח ליחידה. בשל גודלו של האודיטוריום ומיקומו, לא יכול להיות ספק שהתובע היה מודע לקיומו ולכוונה לבנות אותו במועדים הרלוונטיים.

אמנם עלה שהתובע הגיש התנגדות בשנת 2018 לתב"ע שהגישו הנתבעים, שהיוותה תנאי למתן היתר בניה לאודיטוריום, אשר נבנה קודם לכן ללא היתר (ר' חקירת מרואני בפרוטוקול הדיון מיום 23.5.2022 עמוד 2 שורות 49-40). התובע לא התייחס בתצהירו להתנגדות שהגיש לתב"ע, ולהליכים שהתקיימו בנוגע לכך, ולא קיים בחומר הראיות כל מידע השופך אור על נימוקי ההתנגדות ומה נקבע בעקבות כך על ידי הוועדה, והאם יש לאותם הליכים או לעצם ההתנגדות, רלוונטיות לטענות נשוא הליך זה. מכל מקום, ההליך דן במישור הקנייני, ואינו מונע מהתובע להעלות את טענותיו בהיבטים התכנוניים בפני מוסדות התכנון הרלוונטיים.

51. שלישית, כאמור, הכניסה ליחידת התובע היא כניסה פרטית מרחוב קטן וצדדי. הבית המשותף עצמו נמצא במרכז העיר ירושלים, ברחוב נחלת שבעה, באזור של עסקים רבים. רחוב נחלת שבעה וכן הרחובות הסמוכים לו הם מרכזי תיירותי ומתקיימים בהם אירועי תרבות רבי משתתפים. הכניסה למבנה לצורך מעבר לאודיטוריום היא מרחוב נחלת שבעה דרך הלובי המשותף של הבית המשותף, או מכיכר המוזיקה הנמצאת ברחוב המקביל, ולא מהסמטה דרכה ניתן להיכנס ליחידת התובע. למעשה, אין כל צורך לעבור בסמטה בה נמצאת הכניסה ליחידת התובע כדי להגיע לאודיטוריום. שני הרחובות האחרים מהם ניתן להיכנס לבית המשותף ומשם לאודיטוריום הם רחובות עמוסים ממילא במרכז העיר, המובילים הן לעסקים רבים והן לאירועים המתקיימים ברחובות הסמוכים. הן מהאמור והן מביקורי במקום שוכנעתי כי קיומו של האודיטוריום בבית המשותף, גם אם יתקיימו בו אירועים רבי משתתפים, לא יהווה בדרך כלשהי הפרעה ליחידת התובע. בהקשר זה יש מקום להזכיר שנכס התובע אינו דירת מגורים ומעולם לא יועד להיות דירת מגורים, ובמצבו הנוכחי, הקיים כבר שנים רבות, הוא מוזנח ונראה כמקום אחסון.

התובע עצמו עזב את הארץ בשנת 1969 (ר' תשובתו בחקירה נגדית בפרוטוקול הדיון מיום 15.11.2021 עמוד 2 שורות 19-17), מתגורר בארצות הברית, ובשנים האחרונות כמעט שלא ביצע שימוש ביחידה האמורה, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו. גם השימוש שנעשה מטעמו בעבר ביחידה היה למטרות תרבותיות כפי שפירט בתצהירו (סעיף 19), עניין שיכול לתמוך באפשרות הפוכה, של השבחת היחידה בעקבות בניית האודיטוריום. גם אם יש באודיטוריום כדי להביא לתעבורת הולכי רגל גדולה יותר ליד הפתח ממנו יורדים ליחידה, דבר שלא הוכח, לא מובן מטענות התובע כיצד יש בכך כדי לפגוע ביחידה. התובע אף לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הציג כל חוות דעת של מומחה מטעמו כדי להוכיח את הפגיעה הנטענת, ואין באמירותיו בתצהירו כדי להוכיח פגיעה כאמור.

לאור האמור, לא שוכנעתי שהאפשרות לקיום אירועים באודיטוריום מהווה פגיעה בנכס התובע.

52. רביעית, טרם בניית האודיטוריום, לתובע היו לכל היותר זכויות המהוות כ-5% מהגג המשותף שהתובע לא טען שהיה לו שימוש כלשהו בו, אף לא שימוש פוטנציאלי. במצב החדש, לתובע כאמור זכויות משותפות באודיטוריום חדיש מבלי שהשתתף בעלות כלשהי מהעלות המשמעותית שנדרשה לבנייתו, וכן זכויות יחסיות בגג החדש, כך שהוא יוצא נשכר.

53. לאור האמור, איני סבורה שיש באודיטוריום, בהיותו רכוש משותף, כדי לפגוע ביחידת התובע או בזכויותיו.

שאלת תום הלב ושימוש לרעה של התובע בזכותו

54. הפסיקה הכירה במצבים חריגים שבהם רשאי יהיה בית המשפט להפעיל שיקול דעת אשר יגביל את בעל זכות הקניין מלממש את זכותו, לאור חובת תום הלב ולאור סעיף 14 לחוק המקרקעין, וזאת גם בהקשר של זכויות בעלי דירות בבית משותף.

בפסק הדין המרכזי בעניין זה, ברע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, נה(1)199, (1999), נקבע בעמ' 279 לפסק הדין:

"תום הלב מניח כי בעל הזכות דואג להבטיח את זכותו, עם זאת תום הלב מבקש למנוע הפעלת הזכות מתוך התעלמות מקיומו של הצד האחר ובהתעלם מהאינטרס החברתי. אכן תום הלב קובע אמת מידה אובייקטיבית של התנהגות הוגנת של בעל זכות המבקש על רקע האינטרס החברתי הכולל להגשים את האינטרס העצמי תוך התחשבות באינטרס של הזולת. עמדתי על כך באחת הפרשות בצייני: "עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים כל אחד לאינטרס של עצמו. עיקרון תום הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם – לא זאב ולא מלאך; אדם לאדם – אדם".

ובהמשך, נקבע ברע"א 6507/19 **וינשל נ' טמיר** (נבו 31.12.2020) בפסקה 4:

"אין חולק כי הזכאות לסעד של צו הריסה כנגד בניה בלתי חוקית כפופה למסננת תום הלב, בהתאם לעקרונות שהותוו ברע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פ"ד נה(1) 199 (1999)"

ר' גם ע"א 8661/10 **נעמה נ' טורקיה**, בפסקה 12 (נבו 19.2.2012), לעניין שיקולים להגבלת הסעדים להם זכאי בעל זכות קניינית, מכח עקרון תום הלב, גם אם זכותו נפגעה על ידי הזולת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

55. הפסיקה הכירה אף במצבים חריגים בטענה שאין לקבל התנגדות של אחד מבעלי הדירות להרחבת דירה של בעל דירה אחר בשל חוסר תום לב [ר' ע"א (חיפה) 835/08 **נטלה צבי נ' עטה פרי**, (נבו 18.11.2009), אשר צומצם בהמשך בעש"א (חיפה) 17181-05-11 **גורי אברהם נ' יאיר פדאל** (נבו 20.9.2011)].

56. במקרה דנן, אף שהיו ליקויים באופן בו התנהלו הנתבעים ובעיקר בהיעדר שיתוף התובע בפעולות שבוצעו מטעמם ברכוש המשותף, ובביצוע עבודות בניה לפני קבלת האישורים הנדרשים, אני סבורה שאלו לא הביאו לפגיעה בתובע מעבר לזו שנטענה במסגרת ההליך הנפרד שננקט על ידו. עם זאת, אני סבורה שנפלו פגמים בהתנהלות התובע, באופן המשליך על תום לבו בהיבטים הנוגעים לתביעה דנן, ועל כן גם אם קיימת פגיעה כלשהי בזכויותיו הקנייניות, בשל עצם אי שיתופו בהחלטות כאמור, או בשל האפשרות לפגיעה בחלקו המזערי ברכוש המשותף, אין בה כדי להצדיק את מתן הסעדים המבוקשים על ידו.

57. לתובע, על פי טענתו, זכויות ביחידה מזה עשרות שנים. למרות זאת מדובר ביחידה מוזנחת, שבמשך מרבית השנים לא הייתה בשימוש כלל, ואף כיום נחזית ככזו שאינה בשימוש. כמו כן כאמור מדובר ביחידה קטנה הנמצאת במרתף, אשר אינה יכולה לשמש כדירת מגורים, המקנה לתובע כ-5% בלבד מהזכויות ברכוש המשותף, בעוד לנתבעים שייכות כל יתר הזכויות. הנתבעים השקיעו סכומים משמעותיים בשיפוץ הבניין כולו, לרבות הרכוש המשותף שבו, תוך שהפכו את השטחים שבבעלותם למוזיאון מוזיקה לטובת הציבור, מבלי לדרוש מהתובע השתתפות כלשהי בגין העבודות שבוצעו ברכוש המשותף. התובע מצדו היה מודע לשיפוצים המתבצעים, שיבח את ה"חזון" ואף ביקש להיות שותף לו, ובמהלך כל השיפוצים המשמעותיים לא טען שיש בהם כדי לפגוע בו, למעט באשר לעניינים בודדים כגון סגירת פתח המילוט ליחידה.

הנתבעים מצדם לא נענו להצעותיו של התובע להיות שותף שלהם בהיבטים אלו, מטעמים מובנים, וביניהם אי השתתפותו בעלויות כלשהן, והיותו בעלים של יחידה קטנה מאד ביחס למכלול השטחים בהם בוצע הפרויקט של המוזיאון וכיכר המוזיקה, והציעו לו לרכוש את היחידה בסכום העולה על שוויה. סירובו של התובע למכור לנתבעים את היחידה, ובמקרה מסוים התניית הסכמתו בקבלת תמורה העולה באופן משמעותי על שווי היחידה (ר' דברי התובע בחקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 15.11.2021 עמוד 4 שורות 23-35) מתפרש על רקע נסיבות אלו כשימוש בעצם הזכות שלו ביחידה כדי ללחוץ על הנתבעים לשתף אותו בהחלטות הנוגעות בעיקרן לנכס **שלהם**, ולכספים רבים שהם השקיעו, אך בשל זכויותיו המצומצמות בבית המשותף.

בנסיבות האמורות, עולה שהתובע לא היה שבע רצון מהתעלמות הנתבעים ממרבית פניותיו בעניינים אלו, ועל כן הגיש את התביעה דנן.

לא מובן מה התועלת שהייתה צומחת לתובע אם היו מתקבלים הסעדים המבוקשים על ידו, ונראה שקבלת הסעדים אף הייתה גורמת לנזקים לבית המשותף, ובכלל זאת לזכויות התובע. לעומת זאת, הנזקים שהיו נגרמים לנתבעים ככל שהסעדים היו מתקבלים, הם עצומים בשל הסכומים המשמעותיים שהשקיעו הנתבעים לצורך השיפוץ המקיף של הבית המשותף.

לאור האמור אני סבורה שבנסיבות דנן הגשת התביעה והיקף הסעדים שהתבקשו בה נוגעים בחוסר תום לב, באופן המחזיק את המסקנה שגם אם קיימת פגיעה מזערית כלשהי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בזכויותיו הקנייניות של התובע, הרי שהתועלת שהפיק התובע מפעולות הנתבעים גדולה לאין שיעור, ואין בפגיעה נטענת כאמור כדי להצדיק את הסעדים שהתבקשו על ידו.

שימוש באחוזה בניה משותפים

58. מלבד טענה כללית שהנתבעים עשו שימוש באחוזה בניה משותפים, אף שהתקנון אינו קובע הוראות בעניין, לא פירט התובע מהו היקף אחוזי הבניה שיש לבית המשותף, ומהו השימוש שעשו הנתבעים בנוגע לאחוזה בניה כאמור.

59. על פי הפסיקה, אחוזי בניה הם נכס שבבעלות בעלי הדירות בבית המשותף, ובהיעדר הוראות בתקנון, ההנחה היא שיש לחלק את אחוזי הבניה בהתאם לחלקם היחסי של בעלי הדירות ברכוש המשותף. מכאן שלכאורה לתובע זכות לכ-5% מאחוזה הבניה הבלתי מנוצלים של הבית המשותף.

60. בכל הנוגע לעבודות שבוצעו על ידי הנתבעים טרם בניית האודיטוריום, התובע טען כאמור טענות כלליות ולא הוכיח שנעשה שימוש באחוזה בניה בלתי מנוצלים על ידי הנתבעים.

61. באשר לאודיטוריום, מטענות התובע עולה שהבקשה להיתר שהגישו הנתבעים ונדונה ברשות הרישוי ב7.4.2014, וכללה בין היתר את הבנייה בגג הבית המשותף, הוכפפה ביום 12.12.2016 להגשת תכנית מתוקנת, והיתר כאמור לא ניתן (סעיפים 29-31 לתצהיר התובע). כן טען שהנתבעים הפקידו תכנית לצורך קידום רישוי האודיטוריום, והתובע התנגד לתכנית כאמור (ר' חקירתו הנגדית של אדר' מרואני בפרוטוקול הדיון מיום 23.5.2022 עמוד 4 שורות 26-35). במצב דברים זה, התובע לא הציב תשתית ראייתית להיקף השימוש שעשו הנתבעים באחוזה בניה, ומה היקף אחוזי הבניה העודפים שהיו קיימים טרם בניית האודיטוריום. כחלק מכך, התובע לא הוכיח שקיימים לזכותו אחוזי בניה בבית המשותף אשר נעשה בהם שימוש לצורך בניית האודיטוריום, או שידרש בהם שימוש לצורך היתר בניה לאודיטוריום ככל שיאושר. אציין שגם אם היה מוכיח התובע שימוש קיים או צפוי באחוזה בניה כאמור, עדיין היה מקום לבחון את הפגיעה בתובע בין היתר בהתחשב בכך שהנתבעים הם שקידמו על חשבונם את התכנית שתאפשר בנייה על גג הבית המשותף, בכך שהבנייה על הגג התבקשה ליעוד מסוים, וספק אם היו מאושרים אחוזי בניה לטובת ייעודים אחרים, בכך שהתובע התנגד לתכנית, וכן בכך שהאודיטוריום הוא רכוש משותף, כך שבסופו של דבר, אחוזי הבניה נטענים ככל שנוצלו לבנייתו, משרתים גם את התובע. מכל מקום, אופיו של הסעד האמור הוא עניין שבמומחיות, והיה על התובע להציג חוות דעת מומחה כדי להוכיח את טענותיו לעניין עצם הפגיעה והיקפה.

62. באשר לעצם בניית האודיטוריום ללא היתר בניה, הרי שמדובר בטענה תכנונית, שכאמור, אינה בסמכות ערכאה זו. מובן שאין בכך כדי לגרוע מזכותו של התובע להמשיך ולנקוט בהליכים בהיבטים תכנוניים או מזכותו של וועדות התכנון לפעול בעניין. אוסיף על כך, שעצם העובדה שבוצעה בנייה ללא היתר ברכוש משותף, אינה מקימה זכות תביעה לתובע, שכן עליו להצביע על פגיעה שנגרמה כתוצאה מבניה כאמור. בהקשר דומה, בנוגע לעילות נזיקיות, שאינן בסמכות ערכאה זו, נקבע באשר לבנייה בניגוד לחוקי התכנון, שאין בעשיית המעשה האסור כשלעצמו כדי להקים זכות תביעה, וכי על התובע צו מניעה לעמוד בתנאי סף של "פגיעה מוחשית" [ר' ע"א 6121/99 (מחוזי ירושלים) **החברה להגנת הטבע נ' עמותת בית הכנסת הגדול**, פ"מ תשנ"ט (2) 807, 813 (1999)], וכן ת"א 70041-01-20 (שלום ת"א) **נבוא פיננסים ומשכנתאות בע"מ נ' דן אולשטיין** (נבו 10.5.2023)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/33/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

סעדים בנוגע לבנייה עתידית ולמניעת נקיטה בהליכי רישוי

63. מלבד האודיטוריום שנדון לעיל, לא הוכיח התובע שהנתבעים עומדים לבצע בנייה נוספת ברכוש המשותף או כזו העלולה לפגוע ביחידה שבבעלותו, לפיכך אין מקום למתן סעד תיאורטי בדבר איסור בניה עתידית. כמו כן כאמור, ערכאה זו אינה עוסקת בהיבטים תכנוניים ומילא לא קיימת סמכות לאסור על הנתבעים לנקוט בהליכי רישוי.

בקשה לפיצול סעדים

64. התובע ביקש בכתב התביעה ובסיכומיו לפצל את סעדיו כדי לאפשר לו לתבוע את מלוא נזקיו הכספיים הנובעים מהסגת גבול ומבניה על רכוש משותף. התובע לא הגיש בקשה לפיצול סעדים, ודי בכך כדי לדחות את בקשתו.

65. עם זאת, כפי שנקבע בפסיקה, לא קיימת סמכות לערכאה זו לדון בסעדים כספיים נזיקיים, למעט בסעד נזיקי הנוגע להסגת גבול כמור בסעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין [ר' לדוגמה עש"א 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.19)]. לאור האמור, באשר לסעדים נזיקיים שאינם נוגעים להסגת גבול, אין צורך בפיצול סעדים, ואין מניעה שהתובע יפנה בתביעה לערכאה מתאימה לעניין נזקיו הנטענים, ככל שנזקים כאלו קיימים לטענתו גם לאור תוצאות הליך זה. בנוגע לסעדים נטענים בשל הסגת גבול, הרי שלא הוכחה כל הסגת גבול, לא הוכחו נזקים בגין הסגת גבול נטענת, ועל כן הטענה נדחת.

סיום

66. לאור האמור, הסעדים בכל הנוגע לשינויים שבוצעו ברכוש המשותף (שאינו האודיטוריום), וכן יתר הסעדים, נדחים. יובהר כי בנסיבות העניין, הנתבעים אינם רשאים לדרוש מהתובע תשלום בגין השינויים שביצעו.

67. באשר לאודיטוריום, ולאור הנימוקים שפורטו לעיל, עולה שהאודיטוריום הוא רכוש משותף, ועל כן החלטות משמעותיות בעניינו צריכות להתקבל באסיפה הכללית כדין. בנסיבות העניין, אני מוצאת מקום להבהיר, שגם בנוגע לאודיטוריום, לא ניתן יהיה לחייב את התובע בהוצאות הנוגעות לבנייתו, לרבות הוצאות הכרוכות בהתנהלות התכנונית הנדרשת לאישורו או לשינויים שיידרשו בו וכל הנוגע מכך. מכיוון שהאודיטוריום הוא רכוש משותף, וכפי שהוסכם על ידי הנתבעים כעולה מטענותיהם, הרי שהכנסות מהאודיטוריום ככל שיתקבלו, יהיו חלק מכספי הרכוש המשותף, ועל כן יש להעבירם לחשבון הבנק של הנציגות, ולנהלם על ידי נציגות הבית המשותף לטובת כלל בעלי הדירות.

כל האמור כמובן אינו גורע מסמכות רשויות התכנון לקבל החלטות רלוונטיות לעניין האודיטוריום.

68. מכיוון שעיקר סעדי התביעה נדחו, ויחד עם זאת בשל התנהלות הנתבעים אשר במהלך תקופות ארוכות בחרו שלא לשתף את התובע בהחלטות הנוגעות לניהול הרכוש המשותף, אני קובעת שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, ג' סיון תשפ"ג, 23 מאי 2023, בהיעדר הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/33/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים